EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI, M.D. PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,

O **SOLIDARIEDADE,** partido político inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.532.307/0001-07, com sede na SRTVS QD 701, Bloco O, Sala 278, Ed. Multiempresarial - DF - Asa Sul - Brasília - DF, neste ato presente por seu Presidente, Sr. **PAULO PEREIRA DA SILVA**, portador da cédula de identidade RG nº 10.273.141-X e inscrito no CPF/MF sob nº 210.067.689-04, domiciliado na Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados, Gabinete: 217 - Anexo: IV, Brasília/DF, CEP: 70160-900, por intermédio de seu procurador firmado *in fine* nos termos do instrumento de outorga especial em anexo, com fulcro nos art. 102, I, "a" e art. 103, VIII, da Constituição Federal de 1988 e nos arts. 2º, VIII, da Lei Federal nº 9.868/1999, vem propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
(COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR),

em face do inciso I do artigo 3º da Medida Provisória nº 881, editada em 30 de abril de 2019, e do inciso I do artigo 2º e §1º do artigo 2º da Resolução nº 51 do Ministério da Economia, editada em 11 de junho de 2019, por violação ao **artigo 6º, ao inciso II do artigo 23, ao artigo 196 e ao artigo 197 da Constituição Federal de 1988,** nos termos postos a seguir.

I. DA INTRODUÇÃO.

1. A presente ADI tem por escopo obter por parte deste Pretório Excelso decisão declaratória de inconstitucionalidade, com caráter vinculante, *erga omnes* e efeitos *ex tunc* e *ex nunc*, quanto à disposição normativa elencada acima. Explica-se.

2. Em 30 de abril de 2019, foi editada pelo Exmo. Presidente da República Jair Messias Bolsonaro a Medida Provisória nº 881, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e análise de impacto regulatório.

3. Como é cediço, o instrumento ficou popularmente conhecido, e difundido pela mídia, como "MP da Liberdade Econômica", que possibilitaria ao cidadão brasileiro o exercício de atividade de baixo risco em propriedade privada ou de terceiros, desde que consensualmente, sem maiores entraves e empecilhos burocráticos que dificultam o acesso ao empreendedorismo.

4. Ocorre que, não obstante tenha havido a edição de Resolução nº 51, de 11 de junho de 2019 pelo Ministério da Economia, que traz uma série de diretrizes para o corpo da Medida Provisória nº 881 – especificando quais atividades se enquadrariam no conceito de "baixo risco" que compreende o bojo da nova norma –, a MP concede liberdade econômica ao arrepio de garantias constitucionais e expõe os cidadãos a perigos sanitários e de saúde que podem desencadear consequências danosas, sem que o próprio instrumento normativo disponha sobre mecanismos de reparação ou de responsabilização.

5. Esclarecendo: na hipótese em apreço, a MP retira a obrigatoriedade/necessidade de "atos públicos de liberação da atividade econômica" (inciso I do artigo 3º), ao passo que define "atos públicos de liberação da atividade econômica" a licença, a autorização, a inscrição, o registro, o alvará e os demais atos exigidos, com qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição prévia para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a instalação, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros (§5º do inciso II do artigo 1º).

6. Logo, depreende-se que alvarás de funcionamento, inclusive os regulados pela vigilância sanitária, ficam excluídos do rol condicional para que as atividades econômicas sejam desenvolvidas sem maiores entraves e complicações para o pequeno empreendedor.

SRTVS QD 701, Bloco O, Sala 278, Ed. Multiempresarial-DF - Asa Sul - Brasilia - DF

7. Entretanto, necessário pontuar que algumas das atividades permitidas pela nova norma encontram barreiras constitucionais que carecem de atenção desta Suprema Corte, mormente por estarem relacionadas às **questões de saúde pública, posto que a ausência de alvarás que atestem a idoneidade de condições de higiene na produção/comércio dos alimentos/serviços, sob pena de incorrer em danos coletivos que ultrapassariam a razoabilidade.**

8. Conforme se depreende da leitura da **RESOLUÇÃO Nº 51, DE 11 DE JUNHO DE 2019**, em seu anexo I, considerou-se a divisão das atividades, nos termos da Medida Provisória objurgada, em "*baixo risco ou baixo risco A*", "*médio risco ou baixo risco B*" e "*alto risco*". A definição se encontra estabelecida nos incisos do artigo 2º da referida Resolução.

9. As atividades que se enquadrariam no inciso I ao artigo 3º da MP nº 881/2019 estariam na categoria de baixo risco ou "*baixo risco A*" (inciso I do artigo 2º da Resolução nº 51/2019), cujo efeito específico e exclusivo é de dispensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento.

10. Para referendar as práticas comerciais desembaraçadas de qualquer entrave burocrático, a Resolução em comento, complementando a Medida Provisória vergastada, criou o Anexo I, que disciplina as atividades que se enquadrariam no permissivo excepcional criado para a facilitação das atividades econômicas.

11. Da leitura do sobredito Anexo I extrai-se preocupação por estar contra os direitos constitucionais de saúde e políticas públicas que reduzam a exposição a doenças – artigo 6º, inciso II do artigo 23, artigo 196 e artigo 197 CF/88 –, pois facilita o desenvolvimento de atividades que necessitam de cuidados higiênicos para que não haja a disseminação de moléstias de forma coletiva. Transcrevem-se, adiante, as atividades que pretende demonstrar a este Excelso Pretório, cujas informações foram extraídas diretamente da Resolução nº 51/2019, a saber:

XLIV	9602-5/01	Cabeleireiros, manicure e pedicure (Código CNAE:9602501)
CLXVII	1092-9/00	Fabricação de biscoitos e bolachas (Código CNAE:1092900), desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de produto artesanal.
CLXX	1095-3/00	Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos (Código CNAE:1095300), desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de especiaria ou condimento desidratado produzido artesanalmente.
CLXXI	1093-	Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes (Código

	7/02	CNAE:1093702), desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de produto artesanal.
CLXXIII	1094-5/00	Fabricação de massas alimentícias (Código CNAE:1094500), desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de produto artesanal.
CLXXVI	1091-1/02	Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria (Código CNAE:1091102)
CLXXVII	1093-7/01	Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates (Código CNAE:1093701), desde que o resultado do exercício da atividade econômica não será diferente de produto artesanal.
CLXXXVIII	5611-2/03	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e Similares (Código CNAE:5611203)

12. Mostra-se claro que a MP da Liberdade Econômica cria permissivo para que o cidadão que desejar operar alguma das atividades acima descritas não necessite de permissão de funcionamento, inclusive de vigilância sanitária – o que criaria estímulo à recuperação lenta que o país enfrenta, hodiernamente, na economia.

13. Em entrevista concedida aos veículos de comunicação[1], o Ministério da Economia, nas palavras de seu Exmo. Secretário Especial, Sr. Paulo Uedel, atesta que a "*MP vincula decisões administrativas. Outro inciso trata da questão da boa-fé, da presunção de que as pessoas são honestas até que se prove o contrário (...) a MP cria uma espécie de imunidade burocrática para quem quer inovar desde que isso não gere risco à saúde pública (...)*"

14. Ao assim proceder, o dispositivo impugnado insiste, diretamente, em deixar que o indivíduo opere suas atividades sem qualquer fiscalização, como prova de presunção de boa-fé, sem o mínimo de condições de higiene comprovadas. Tal permissivo gera a possibilidade de condições de armazenamento, higienização e esterilização de equipamentos precários (no caso das atividades de manicure e pedicure constantes na tabela acima), de armazenamento de matéria-prima e acondicionamento de insumos para os casos de fabricação de bens alimentícios, além da procedência dos alimentos utilizados nas atividades de lanchonetes e congêneres.

15. Logo, o Estado endossa ao cidadão a obrigação de fiscalização, deixando do crivo da falta de técnica e conhecimento – além da possível falta de razoabilidade – a operação de atividades que podem comprometer a saúde de forma coletiva; manteve-se, até então, silente quanto às consequências coletivas que seriam oriundas de tais condições de exercício da atividade econômica. Em resumo, opta o Estado

[1] https://epoca.globo.com/com-mp-da-liberdade-economica-governo-vai-focar-no-essencial-diz-paulo-uebel-23635579

por remediar, ao revés de prevenir.

16. Se não há o mínimo de fiscalização e vigilância sobre as condições em que bens que serão ingeridos ou instrumentos que podem introduzir bactérias na corrente sanguínea, abre-se precedente para que a produção ocorra de forma displicente e ao arrepio do que prevê o artigo 196 da Carta Magna, ao dispor que a *"saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"*.

17. A redação adotada pelo artigo 3º, *caput* e seu inciso I, da MP permite que haja a criação e comercialização de produtos que podem ser realizados em condições higiênicas precárias, contando com a presunção de boa-fé para o sucesso da medida. Demais disso, neste sentido, o próprio Ministério da Economia, no excerto transcrito alhures, frisa que o desembaraço burocrático funcionará desde que "*desde que isso não gere risco à saúde pública*". **No entanto, não cria a MP nº 881/2019 quaisquer elementos que combatam a evidente facilidade de comprometimento de saúde pública que está claramente evidenciado pelo permissivo legal.**

18. A Medida Provisória combatida se traduz em verdadeiro instrumento de afronta à saúde pública, ainda que a evocada alegação para sua existência seja calcada em limites que supostamente preservariam a coletividade – embora o permissivo legal, em si, não cria nenhuma forma de resguardar a sociedade de possíveis práticas anti-higiênicas que poderiam ser praticadas.

19. *Verbi gratia*, pode-se citar o uso de alimentos perecíveis fora do seu tempo de consumo, uso de insumos fora do prazo de validade, origem dos alimentos utilizados no preparo dos produtos vendidos, utilização de equipamento para produção de alimentos ou de serviço de beleza sem acondicionamento adequado e em condições esterilizadas para sua utilização, preparo de alimentos em condições insalubres, dentre outras inúmeras hipóteses com sua ocorrência claramente facilitada pela edição da Medida Provisória.

20. Neste viés, o **inciso I do artigo 3º da Medida Provisória nº 881, editada em 30 de abril de 2019** – em toda a sua cadeia normativa, complementado pelo §5º do inciso II do artigo 1º da MP e pela Resolução nº 51/2019 do Ministério da Economia – é aqui impugnado, porque regulamenta procedimentos administrativos que podem se mostrar completamente abusivos e ilegítimos, e que ferem as garantias e direitos fundamentais do cidadão jurisdicionado.

II. DA PRELIMINAR DE LEGITIMIDADADE ATIVA.

21. O inciso VIII do artigo 103 da Constituição Federal de 1988 e o inciso VIII do artigo 2º da Lei Federal nº 9.868/1999 conferem legitimidade a partido político com representação no Congresso Nacional para a propositura de ações do controle concentrado, como a presente ADI. A documentação ora colacionada comprova que o Autor, partido político SOLIDARIEDADE (SD), atende a tal exigência.

22. Acrescente-se que o Autor foi constituído nos termos da Lei nº 9.096/1995, devidamente registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas e no Tribunal Superior Eleitoral, há mais de um ano e tem como objetivo, em seu programa, a defesa dos princípios constitucionais e da probidade administrativa, preceitos aqui objeto de defesa, consoante será detalhado a seguir.

III. DA MOTIVAÇÃO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

23. O Autor é cônscio de que sua condição de partido político com representação no Congresso Nacional é suficiente para a legitimação para propositura da presente ADI, não sendo necessária a demonstração de pertinência temática. Contudo, considera-se relevante, para fins de clareamento da pretensão deste instrumento, tecer comentários sobre a motivação da propositura da presente ADI.

24. Impende salientar que a motivação maior da propositura desta Ação Direta de Inconstitucionalidade está calcada no caráter imediato e emergencial da Medida Provisória, que está em vias de se transformar em lei. Os pontos destacados neste instrumento possuem condão de evidenciar que há perigo iminente de complicações sanitárias e generalizadas perante a sociedade, mormente pelo fato de o comerciante/empreendedor não ter mais de se preocupar com condições de higiene e adequação na produção/fabricação dos produtos e serviços descritos na tabela supramencionada.

25. Ao que tudo indica, o Estado endossa a obrigação de cuidado exclusivamente ao empreendedor, a quem facilita a abertura de comércio, optando por punir o agente que contrariar a "boa-fé presumida pelo governo", possibilitando/facilitando que inúmeras pessoas sejam expostas a riscos que certamente terão de contornar individualmente; tal hipótese, por si, revela-se assustadora, especialmente se considerarmos alguns casos escabrosos que já ganharam notória repercussão nacional, como a venda de

empadas com carnes humanas no município de Garanhuns/PE[2].

26. Decerto, sem controle sanitário, as hipóteses de utilização de matéria-prima sem procedência e controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA certamente poderão culminar em situações exageradamente preocupantes, que têm condão de causar um dano coletivo sobre o qual o Estado não terá controle.

27. A título figurativo, tem-se a Portaria 1428/93 da ANVISA, cujas informações foram retiradas de planilha de atos normativos constantes no sítio eletrônico do órgão[3] e que demonstram que o controle sanitário já vem sendo executado sob a ótica do aqui esposado, observando que as boas práticas na produção de alimentos – e, por analogia, em serviços de embelezamento –, devem ser considerados. Confira-se:

1993	PRT	1428	26/11/1993	DOU nº 229, Seção 1, Pág. 18415	02/12/1993
Aprova o "Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos", as "Diretrizes para o Estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na Área de Alimentos" e o "Regulamento Técnico para o Estabelecimento de Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ's) para Serviços e Produtos na Área de Alimentos".					
Regularização de serviços e estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária e Boas Práticas					
Boas Práticas de Fabricação (BPF) em estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos					

28. Logo, a manutenção do dispositivo enfrentando iria de encontro com as inúmeras disposições e práticas da ANVISA para manter o mínimo de condições sanitárias para a produção dos serviços que a Medida Provisória elencou como categoria de "*baixo risco A*", violando, frontal e especialmente, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, além dos já citados artigos 6º e inciso II do artigo 23 do mesmo Diploma.

29. Demais disso, o já mencionado artigo 197 da Constituição Federal de 1988 dispõe que são "*de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser*

[2] https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/04/13/acusada-de-canibalismo-vendia-empadas-com-carne-humana-em-garanhuns-pe-diz-policia.htm
[3] http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/

feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado".

30. Não há plausibilidade, com efeito, em ato legitimado pela Medida Provisória contrariar direito coletivo constitucionalmente resguardado ao argumento de "facilitar" a operação do pequeno empreendedor – enquanto, concomitantemente, o expõe à ausência de tecnicismo necessário para a boa-prática do negócio que pretende executar.

31. Cria-se, portanto, hipervulnerabilização do pequeno empreendedor que se enquadraria nas atividades de "*baixo risco A*" por permitir que execute trabalhos sem o efetivo controle e, em razão da possível imperícia nas boas-práticas sanitárias, se depare com prejuízos e transtornos ainda maiores – além de eventual responsabilização na esfera cível e criminal.

32. Em que pese o §3º do artigo 3º disciplinar sobre fiscalização e enquadramento posterior, *de ofício ou como consequência de denúncia encaminhada à autoridade competente,* **mostra-se como critério falho e que permite, em demasia, que danos coletivos sejam perpetrados até que o ato púbico de vistoria ocorra**.

33. Note-se que o próprio dispositivo em comento elenca como possibilidade a "*denúncia encaminhada*", pressupondo a existência de irregularidade experimentada pelo próprio usuário/consumidor do serviço ou produto alimentício – e possível dano advindo: infecção ou infecção alimentar, insumos de procedência duvidosa, dentre outros já elencados neste instrumento.

34. Verifica-se que até este presente momento não há qualquer impugnação específica ao dispositivo aqui enfrentado por via de ação estrutural, tampouco pela motivação aqui exposta. Destarte, **ainda não há qualquer enfrentamento sobre o tema nesta Suprema Corte**, sendo necessária e imediata providência neste sentido por haver, diariamente, constantes e flagrantes violações aos direitos constitucionais que serão demonstrados adiante.

35. Considerando que nas ações estruturais se busca tutelar os direitos fundamentais através de reformas estruturais e da modificação do arranjo institucional dos órgãos públicos[4], eis a motivação para o manejo desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

[4] DANTAS, Eduardo Sousa. **Ações Estruturais e o estado de coisas inconstitucional – a Tutela dos direitos fundamentais em casos de graves violações pelo Poder Público**, Curitiba, Juruá Editora, 2019, p. 201.

IV. DO DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO – INCISO I DO ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 881, EDITADA EM 30 DE ABRIL DE 2019, E INCISO I DO ARTIGO 2º E §1º DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO Nº 51 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

IV.I. DA VIOLAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE – ARTIGOS 6º, 23, II, 196 E 197 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

36. Eis a redação inicial e introdutória da Medida Provisória nº 881, que define seu propósito e o conceito de "*atos públicos*":

> Art. 1º Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do disposto no inciso IV do caput do art. 1º, no parágrafo único do art. 170 e no caput do art. 174 da Constituição.
>
> § 5º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, consideram-se atos públicos de liberação da atividade econômica a licença, a autorização, a inscrição, o registro, o alvará e os demais atos exigidos, com qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição prévia para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a instalação, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros.

37. Em seguida, cria-se o permissivo que facilitaria o início da atividade empresarial considerada pela Resolução nº 51/2019 do Ministério da Economia como de "*baixo risco A*":

> Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto

> no parágrafo único do art. 170 da Constituição:
>
> I - desenvolver, para sustento próprio ou de sua família, atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica;

38. Como adiantado acima, o inciso I do artigo 3º da MP, objeto de discussão sobre sua inconstitucionalidade, padece de vícios em sua essência por se tratar de flagrante afronta à saúde pública e condições sanitárias em geral. Isso porque, conforme a conclusão sobre a lição de Pedro Lenza[5], o direito à saúde é um dever substancial do Estado, sendo inerente e intrínseco ao direito à vida com dignidade, concretizando-se assim como direito fundamental e social sobre o qual o ser humano figura como destinatário da tutela na atual Constituição Federal da República de 1988.

39. Molda-se, portanto, a garantia de proteção à saúde de forma preventiva e curativa, não se limitando, exclusivamente, ao tratamento de doenças, mas de políticas públicas que tenham caráter geral sobre tudo que envolve a exposição do cidadão brasileiro à moléstias e riscos coletivos. Conforme o escólio de Germano A. Doederlein Schwartz[6], "*a saúde é, senão o primeiro, um dos principais componentes da vida, seja como pressuposto indispensável para a sua existência, seja como elemento agregado à sua qualidade. Assim a saúde se conecta ao direito à vida*".

40. O que se enfrenta, no caso concreto, é ato de populismo legislativo sem maiores considerações sobre os impactos em direitos coletivos – mormente pelo fato de aumentar o número de exposição a riscos, tanto pelo destinatário final como pelo desenvolvedor da atividade empresarial – e que terá efeito meramente simbólico se comparado aos efeitos nefastos que poderá gerar.

41. Neste sentido, o que, em primeira análise, parece vantajoso e plausível pode ter efeito contrário, especialmente porque a publicização supostamente razoável ao popular *afeta e altera diretamente a percepção da opinião pública sobre a urgência e gravidade do problema, por vezes aumentando a pressão exercida sobre o Estado e os atores sociais para que*

[5] LENZA, Pedro. **Direito constitucional esquematizado**. 12 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008.
[6] SCHWARTZ,Germano André Doederlein. **Direito a Saúde: Efetivação em uma Perspectiva Sistêmica**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 52.

encontrem e implementem uma solução para o caso[7]. Ou seja, cria-se a falsa sensação de elemento facilitador, quando na verdade acaba expondo o empresário a riscos individuais e coletivos.

42. Considerando que os direitos sociais em geral, especialmente o direito à saúde pública e à integralidade de tratamento no Brasil não é efetivado, medidas preventivas para se evitar situações calamitosas e maiores violações constitucionais devem ser observadas e prestigiadas. A Medida Provisória, ao invés de observar justamente o déficit de cuidados com a saúde pública, opta por criar e expandir o cenário danoso que poderá agravar ainda mais o quadro coletivo atualmente enfrentando, como bem observado no magistério de Carlos Alberto Pereira de Castro[8]:

> "Entretanto, em países – tais como o Brasil – que não atingiram o mesmo nível de proteção social que os dos continentes precursores de tais ideias – Europa, América do Norte, Oceania –, o período atual gera problemas de outra ordem: a redução de gastos públicos com políticas sociais, o que, em verdade, significa o não atingimento do prometido Bem-Estar Social".

43. Neste esteio, contribuir para o aumento da violação ao direito à saúde da população geral enseja a discussão acerca da constitucionalidade ou não do dispositivo objurgado, mormente por estar vinculado ao ímpeto de solucionar atraso ou lentidão na economia do Brasil com medidas extremas e imediatistas que deixam de traçar panorama mais expansivo tendo em vista as garantias constitucionais e deveres do Estado.

44. Por corolário lógico, as organizações públicas e privadas – *in casu* o Estado e o pequeno empreendedor que se enquadra na atividade de baixo risco A – devem buscar se adequar ao ambiente legal de reconhecimento de direitos, fiscalizando e efetivando-os antes mesmo da execução judicial, como forma de aumentar a própria legitimidade, obter apoio popular e escapar da pressão exercida pela opinião pública. Espera-se o mínimo de razoabilidade na edição de normas, evitando que o permissivo legal criado na verdade preceda danos coletivos sobre o qual o próprio Estado não terá controle– tampouco conseguirá contornar.

45. Notadamente, é notório o fato de que a tese basilar acerca da inconstitucionalidade do referido dispositivo está embasada na garantia constitucional do

[7] DANTAS, Eduardo Sousa. **Ações Estruturais e o estado de coisas inconstitucional – a Tutela dos direitos fundamentais em casos de graves violações pelo Poder Público**, Curitiba, Juruá Editora, 2019, p. 199.
[8] CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. **Manual de Direito Previdenciário,** 9 ed. Florianópolis: Conselho Editorial, 2008, p. 622.

direito à preservação da saúde e de políticas públicas que combatam ameaças a tal direito (artigos 196 e 197 CF/88). Em uma perspectiva hegeliana, trazida na literatura sueca de Sofia Näsström[9], o próprio Estado libertaria as pessoas de suas responsabilidades para com as outras, estreitando o espaço da solidariedade coletiva direta e reduzindo as pessoas a indivíduos abstratos — ou a materialização da dignidade da pessoa humana "responsável" pelo dano causado em razão da "facilidade" criada pelo Estado; em suma, o próprio Estado criaria o problema que depois se empenharia em solucionar e os indivíduos responderiam na extensão da facilidade criada.

46. A manutenção da desnecessidade de fiscalização preliminar da vigilância sanitária para as atividades delineadas no Anexo I da Resolução nº 51/19 do Ministério da Economia culminaria em uma negatividade abstrata encarnada no Estado que, ao arrepio da existência do elemento regulador da sociedade: a norma.

47. Essa lógica (ou falta de) também nos permite concluir por uma visão hobbesiana do monarca como o Um que, de forma brutal, porém necessária, impõe a coexistência pacífica na multiplicidade de indivíduos (pequenos empreendedores, no caso concreto), que, se deixados por conta própria (como no caso da vigência da MP e o dispositivo que não exige a fiscalização/autorização do Estado), cairiam em um estado em que *homo homini lupus*.

48. Esse estado supostamente "natural" da guerra de todos contra todos seria um produto retroativo do poder imposto do Estado, ou seja, para que esse poder funcione, o Um deveria romper os elos laterais entre os indivíduos.

49. É fato que mencionado artigo da Medida Provisória não dispõe explicitamente acerca da circunstância em que seria realizada a fiscalização ou quais as consequências adviriam do não cumprimento dos requisitos mínimos para a execução das atividades empresariais descritas como "*baixo risco A*". Justamente tal vacuidade é que possibilitaria práticas incompatíveis com o mínimo de saúde e higiene esperados nas atividades comerciais descritas – além da já mencionada imperícia do empresário para condições e boas práticas dos serviços ou produção que pretende realizar.

50. Justamente neste esteio que, ao confrontar as atividades permitidas nos deparamos com produção e comercialização de alimentos, bem como de atividades fins de embelezamento, que exigem aparelhos e instrumentos que, se não observados os procedimentos adequados, podem comprometer a saúde pública.

51. Tais atividades sofrem limitações e condicionantes pela

[9] Sofia Näsström, **The Na-Archical State: Logics of Legtimacy in the Social Contract Condition** (dissertação na Universidade de Estocolmo, Stockholm Series in Politics 99, 2004).

redação do artigo 8º da Lei nº 9782/09, que dispõe *que incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública*.

52. Igualmente, especificamente no que tange às atividades-fim de embelezamento e estética, encontra óbice nos artigos 12 e 25 da Lei nº 6.360/1976. Como tem sido sustentado ao longo desta ADI, as atividades consideradas de baixo risco A que envolvem os serviços de cabelereiro, manicure e pedicure utilizam produtos e instrumentos que necessitam de autorização do Ministério da Saúde para que sejam empregados nos serviços e que, se manuseados inadequadamente, oferecem risco à saúde pública.

53. O artigo 12 da sobredita lei dispõe que *nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde.* O artigo 25, por sua vez, disciplina que *os aparelhos, instrumentos e acessórios usados em medicina, odontologia e atividades afins, bem como nas de educação física, embelezamento ou correção estética, somente poderão ser fabricados, ou importados, para entrega ao consumo e exposição à venda, depois que o Ministério da Saúde se pronunciar sobre a obrigatoriedade ou não do registro*.

54. Com efeito, é nítido que a fiscalização e preocupação com a saúde pública já se encontra positivada em nosso ordenamento pátrio, havendo justamente **a atuação da ANVISA para evitar que haja proliferação de moléstias advindas do manuseio de produtos e serviços sem as observâncias dos procedimentos padronizados para garantir a idoneidade do que será repassado ao consumidor.**

55. A Medida Provisória em comento, de forma contrária, oblitera todos os procedimentos de vigilância já consagrados, cuja ausência expõe o cidadão brasileiro a riscos imensuráveis. Este Excelso Pretório, sobre o tema, já se pronunciou, inclusive se manifestando sobre o propósito e relevância da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no seu papel de fiscalização para prevenção de calamidades de saúde coletivas, *in verbis:*

> RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO DE AGRAVO.
>
> 1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de indenização por dano morais e materiais decorrentes da proibição do uso de equipamentos para bronzeamento artificial, considerada a legalidade da Portaria nº 56/09, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação dos

artigos 5°, cabeça e incisos I, XII, XXII e XXXVI, da Constituição Federal. Afirma afrontados os princípios da isonomia, reserva legal, livre iniciativa, eficiência, direito adquirido, direito de propriedade, bem como contrariados o interesse público e o ato jurídico perfeito. Discorre sobre o direito à exploração do serviço, por possuir o necessário alvará. Diz não comprovada a relação de causa e efeito entre o uso de aparelhos de bronzeamento e casos de câncer de pele. Aponta a responsabilidade civil objetiva do Estado pelo prejuízo sofrido.

2. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos: A Resolução da Diretoria Colegiada n.° 56/09 da ANVISA proíbe em todo território nacional o uso de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, pela emissão da radiação ultravioleta, verbis: Art. 1°. Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. § 1°. Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético. Acerca da controvérsia, é assente o entendimento no TRF4 na manutenção da legislação supra, face à nocividade das radiações ultravioletas emitidas pelos equipamentos, as quais possuem fortes evidências cancerígenas**. Revestida de seu poder de polícia, configura integralmente legal a medida adotada pela ANVISA, a quem compete regular, controlar e fiscalizar produtos e serviços que evolvam risco à saúde pública, nos termos dos artigos 6° e 8° da Lei n° 9.782/99: Art. 6°. A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras**. (…) Art. 8°. Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. **§ 1°. Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência:** I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias; **II - alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários; III - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes**; IV - saneantes destinados à higienização,

desinfecção ou desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos; V - conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico; VI - equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem; VII - imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados; VIII - órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições; IX - radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofármacos e produtos radioativos utilizados em diagnóstico e terapia; X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco; XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação. […] **Cumpre registrar que a atividade profissional da autora submete-se à fiscalização do poder público já que oferece riscos à saúde. Portanto, se sujeita ao poder de polícia conferido à ANVISA, que tem o dever legal de proteção à saúde da população/consumidores, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Nessa perspectiva, a atividade econômica exercida pela parte apelante sofre limitações e condicionantes, inclusive pelas Leis nº 9.782/09, art. 8º, e nº 6.360/76, artigos 12 e 25, que atribuem, respectivamente, à Agência o dever de regulamentar, controlar e de fiscalizar serviços que envolvam riscos à saúde.** Desse modo, ainda que a vedação lhe cause enormes prejuízos econômicos, tal circunstância não autoriza juízo de procedência do pedido indenizatório, dada a relevância do direito em debate, que diz com a saúde pública. O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da Republica, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Acresce que, no caso, o que sustentado nas razões do extraordinário não foi enfrentado pelo Órgão julgador. Assim, padece o recurso da ausência de prequestionamento, esbarrando nos Verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. Este agravo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, ocupando espaço que deveria ser utilizado na apreciação de outro processo.

3. Conheço do agravo e o desprovejo.

4. Publiquem. Brasília, 16 de junho de 2017. Ministro MARCO AURÉLIO Relator

(ARE 5083373-41.2014.4.04.7100 RS - RIO GRANDE DO SUL, Min. Rel. Marco Aurélio, 16 de Junho de 2017) **[grifamos]**

56. Ademais, válido destacar que, caso o empresário, seduzido pela facilidade criada pela Medida Provisória em comento opte em iniciar as atividades dentro do formato possibilitado pela redação da nova norma. Considerando o período de 60 (sessenta) dias prorrogáveis por mais 60 (sessenta), e haja ausência de nova definição ou posicionamento sobre seu teor, ficaria o pequeno empreendedor à míngua dos direitos? Estaria submetido a todos os procedimentos de fiscalização que temos sustentado neste instrumento, traduzindo-se os artifícios da Medida Provisória em mera facilidade momentânea.

57. Daí porque tem sido sustentado que há dupla exposição a riscos: do empreendedor e do cidadão consumidor. Ora, com um possível fim da eficácia da Medida Provisória nos depararíamos com empreendedor irregular com a legislação vigente, o que seria situação de flagrante insegurança jurídica.

58. Mostra-se, portanto, que além da flagrante violação ao direito à saúde, o texto da Medida Provisória, neste trecho, revela a impossibilidade de se optar ou não por iniciar a atividade-fim que pretende o pequeno empreendedor.

59. De certa forma, poder-se-ia falar até em "cinismo normativo", já que praticamente apenas facilita as operações comerciais sem alvarás de vigilância sanitária momentaneamente, permitindo que haja danos à saúde pública advindo da própria política pública promovida pelo governo e que ainda não possui seu objetivo definido – considerando que há mais de 300 (trezentas) emendas parlamentares apresentadas para essa Medida Provisória.

60. Por corolário lógico, o limbo normativo que se forma enquanto atua como permissivo legal para a não observância das boas práticas de higiene, cria mecanismo de ataque à saúde pública sem que o Estado tenha definido como funcionaria a própria exceção criada. Se permite empreender sem a necessidade de alvará, enquanto, concomitantemente, permite a exposição da sociedade aos riscos de saúde advindos de tais práticas. Em contrapartida, o próprio escopo da Medida Provisória se mostra incerto, fragilizado e sem garantia de que seu conteúdo tenha alguma definição após os 120 (cento e vinte) dias de validade – perpetua-se o empreendedor no limbo normativo, as consequências sobre a ausência de alvará de vigilância sanitária mantêm-se indefinidas e o cidadão empresário exposto a toda sorte de incerteza, ao passo que o cidadão consumidor exposto ao risco de saúde.

61. Destaca-se: não se olvida da necessidade de facilitar o

empreendedorismo brasileiro, permitindo a criação de emprego e renda, que contribuirá para o desenvolvimento da economia brasileira. Entretanto, surgem dois direitos colidentes entre si: 1) o direito do cidadão brasileiro à saúde e políticas que combatam a disseminação de doenças de todos os tipos, especialmente as que podem advir da má produção e venda de alimentos, bem como de tratamentos de embelezamento – este garantido constitucionalmente; 2) o direito de iniciar o pequeno negócio sem maiores entraves do Estado, recém-criado, mas que está em vigor contrariando as garantias constitucionais.

62. Se de um lado, busca-se caminho para melhorias nacionais, de outro deixa de se observar o que o Texto Maior prevê, que é a garantia ao direito à saúde do brasileiro.

63. Para Norberto Bobbio[10], o *direito como ordenamento normativo coativo abrange o conjunto de normas de conduta e de organização, constituindo uma unidade e tendo por conteúdo a regulamentação das relações fundamentais para a convivência e sobrevivência do grupo social, tais como relações familiares, as relações econômicas, as relações superiores de poder, também chamadas de relações políticas, e ainda a regulamentação dos modos e das formas através dos quais o grupo social reage à violação das normas de primeiro grau ou a inconstitucionalização da sanção. Essas normas têm como escopo mínimo o impedimento de ações que possam levar à destruição a sociedade, a solução dos conflitos que a ameaçam e que tornariam impossível a própria sobrevivência do grupo se não fossem resolvidos, tendo também como objetivo a consecução e a manutenção da ordem e da paz social.*

64. Neste diapasão, merece destacar que se define a lei como expressão da vontade geral, declara, promulgada e pública, sendo a máxima expressão da racionalidade do Estado, no sentido de que o Estado exprime o interesse universal e a consciência própria do povo organizado[11].

65. Assim sendo, não seria minimamente coerente, tampouco seguro juridicamente, suprimir a força constitucional de um direito já adquirido em detrimento de uma nova tentativa de adequação do Estado brasileiro a novo formato de empreendedorismo – ainda confuso e incerto – que traz, a bem da verdade, embrião de prejuízos e percalços ao pequeno empresário e expõe o grande público aos danos aqui mencionados.

66. É evidente que as arbitrariedades aqui denunciadas refletem a falta de capacidade governamental, conforme prelecionado por Kent Roach e Geoff Budlender ao atribuir tal característica a países em desenvolvimento, asseverando que a sistemática violação de direitos é algo comum em tais territórios, possibilitando a utilização

[10] BOBBIO, Norberto. **Dicionário de Política** / Norberto Bobbio, Nicola Matteuci e Gianfranco Pasquino; tradução Carmen C. Varriale, 5ª ed. – Brasília. Editora Universidade de Brasília. São Paulo. Imprensa Oficial do Estado, 2000, p. 349.
[11] Idem, p. 352.

de amplo leque de mecanismos para a correção de tais falhas por intermédio da utilização de ações judiciais[12] – como no caso em tela, em que almeja o combate ao verdadeiro retrocesso social que se instalará se a inconstitucionalidade do dispositivo enfrentando não seja declarada.

67. Conforme ensinamentos do Ministro Luis Roberto Barros[13], a*s políticas públicas de saúde devem seguir a diretriz de reduzir as desigualdades econômicas e sociais*, sendo de grande valia ressaltar que o direito constitucional à saúde deve ser concretizado observando o máximo de extensão possível, efetivando o direito à vida com dignidade e sem a exposição a riscos endossados pelo próprio Estado, como no caso do permissivo criado pela Medida Provisória objurgada.

IV.2. DA FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL.

68. Conforme o escólio do professor português José Joaquim Gomes Canotilho[14] os direitos econômicos, sociais e culturais estão submetidos às recessões e às crises conjunturais e estruturais. Entretanto, as restrições devem sofrer limitações possibilitando o respeito à dignidade humana, demonstrando que o Princípio da Proibição de Retrocesso Social surge como espécie de limite em relação às restrições decorrentes de situações econômicas – como a motivação da Medida Provisória, no caso em apreço. Confira-se:

> "A proibição de retrocesso social nada pode fazer contra as recessões e crises econômicas (reversibilidade fática), mas **o princípio em análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos (ex: segurança social, subsídio de desemprego, prestações de saúde), em clara violação do princípio da proteção da confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito econômico, social e cultural, e do núcleo essencial da existência mínima inerente ao respeito pela dignidade humana. O reconhecimento desta protecção de direitos prestacionais de propriedade,**

[12] ROACH, Kent; BUNDLENDER, Geoff. **Mandatory Relief and Supervisionary Jurisdiction: when is it appropriate, just and equitable?** The South African Law Journal, p. 345, *apud*, DANTAS, Eduardo Sousa. **Ações Estruturais e o estado de coisas inconstitucional – a Tutela dos direitos fundamentais em casos de graves violações pelo Poder Público**, Curitiba, Juruá Editora, 2019, p. 99.

[13] BARROSO, Luis Roberto. **Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial**. *Revista de direito social*. Coord.Wagner Baleira. Editora Notadez: Porto Alegre. nº: 34. Abr/Jun. 2009, p. 34.

[14] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito constitucional e teoria da constituição**. 4 ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 332-333.

> **subjectivamente adquiridos, constitui um limite jurídico do legislador e, ao mesmo tempo, uma obrigação de prossecução de uma política congruente com os direitos concretos e as expectativas subjectivamente alicerçadas**"

69. O princípio da proibição de retrocesso social não está expressamente positivado no nosso ordenamento jurídico.[15] Inobstante, é possível deduzi-lo de outros princípios e argumentos de matriz-jurídico constitucional.

70. Primeiramente, do **princípio da segurança jurídica e da confiança**, consectários do **Estado Democrático e Social de Direito** (art. 1º, *caput*, da CF/1988).

Segundo Jorge Miranda, a segurança jurídica, num plano subjetivo, confere ao cidadão o direito à proteção da confiança depositada nos atos do poder político que contendam com suas esferas jurídicas. De modo correlato, ao Estado incumbe o dever de boa-fé, ou seja, "o cumprimento substantivo, e não meramente formal, das normas e de lealdade e respeito pelos particulares". Já a proteção da confiança revela-se também no que atine ao regime dos direitos fundamentais, no não retorno de concretização de normas legais que confiram exequibilidade a normas constitucionais não exequíveis consagradoras de direitos econômicos, sociais e culturais.[16]

Nesse contexto, a segurança jurídica e a proteção da confiança podem significar um sentimento comum e generalizado de gestão de expectativas no quadro do Estado social, inviabilizando a prevalência da competência decisória do legislador em todo e qualquer caso sobre o princípio material da proteção dos direitos fundamentais.[17]

71. Segundamente, do **princípio da dignidade da pessoa humana** (art. 1º, III, da CF/1988).

Os direitos econômicos, sociais e culturais são posições jurídico-subjetivas exigíveis judicialmente quanto ao conteúdo do "mínimo existencial", compreendido este como um direito às condições mínimas de existência humana digna que

---

[15] MACHADO, Vítor Gonçalves. Uma análise sobre o (ainda incipiente) princípio da proibição de retrocesso e sua importância para os direitos fundamentais. In: **Revista de direito constitucional e internacional**, v. 20, n. 79, p. 149-165, abr./jun. 2012.
[16] MIRANDA, Jorge. **Manual de direito constitucional – Tomo IV. Direitos fundamentais**. 4. ed. Coimbra: Coimbra Ed., 2008, p. 279.
[17] QUEIROZ, Cristina. **O princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais: princípios dogmáticos e prática jurisprudencial.** Coimbra: Coimbra Ed., 2006, p. 71-72.

não pode ser objeto de intervenção do Estado na via dos tributos e que ainda exige prestações estatais positivas, como ensino fundamental, os serviços de pronto-socorro, as campanhas de vacinação pública, etc.[18]

Destarte, "exigindo a satisfação – por meio de prestações positivas (e, portanto, de direitos fundamentais sociais) – de uma existência condigna para todos, (*a dignidade humana*) tem como efeito, na sua perspectiva negativa, a inviabilidade de medidas que fiquem aquém deste patamar".[19]

72. Terceiramente, do comando de **máxima eficácia dos direitos fundamentais,** contido no art. 5º, § 1º da CF/1988, em sua dimensão negativa.

Como bem lembra o Exmo. Ministro Roberto Barroso, em sede doutrinária, "todas as normas constitucionais, em maior ou menor grau, são dotadas de eficácia. Não faz sentido afirmar que uma norma, integrante do corpo da Constituição, apresente-se despossuída da capacidade de produção de quaisquer efeitos jurídicos próprios; caso contrário, não se trataria de uma norma jurídica".[20]

O efeito jurídico mais comum é a possibilidade de aplicar-se determinada norma diretamente, concretizando, no mundo dos fatos, aquilo que nela se dispôs, sem a necessidade de qualquer espécie de ação interveniente. "*Há normas constitucionais, entretanto, que não são capazes de produzir essa espécie de efeito sem a necessária intervenção do legislador; é o caso típico das normas constitucionais programáticas*".[21] Inobstante, a estas se reconhece uma **eficácia negativa**, pela qual **serão considerados inválidos – ou revogados, caso anteriores à promulgação da Constituição – todas as normas ou atos que o contravenham**.[22]

Pois bem: se todas as normas constitucionais, como normas de hierarquia superior, gozam destas eficácias como consequência de sua posição formal, as normas de direitos fundamentais gozam do reforço do art. 5º, § 1º da CF/1988, segundo o qual "as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata". "Assim, tem-se, na máxima eficácia dos direitos fundamentais, um mandado constitucional que agrega a estas normas, para além das virtualidades de que desfrutam por serem normas constitucionais, um *plus* que determina aos poderes estatais o direcionamento de sua atuação

[18] TORRES, Ricardo Lobo. *O* **direito ao mínimo existencial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 35-36.
[19] SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais**. 14ª ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 446.
[20] BARROSO, Luís Roberto. Benefício previdenciário: princípio constitucional de proteção ao idoso: vedação do retrocesso. In: **Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro**, n. 13, p. 67-75 2003.
[21] Id., *ibid.*, p. 71.
[22] BARCELLOS, Ana Paula de. Normatividade dos princípios e o princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988. In: **Revista de direito administrativo,** n. 221, p. 159-188, jul./set. 2000.

no sentido de conferir-lhes máxima eficácia".[23]

Em que pese a circunstância de que a situação topográfica do dispositivo poderia sugerir uma aplicação da norma contida no art. 5°, § 1º, da CF/1988 apenas aos direitos individuais e coletivos (a exemplo do que ocorre com o § 2° do mesmo artigo), o fato é que esse argumento não corresponde à expressão literal do dispositivo, que utiliza a formulação genérica "direitos e garantias fundamentais", tal como consignada na epígrafe do Título II da *Lex Suprema*. **Logo, o comando inserto no art. 5º, § 1 º, da Constituição Federal deve ser interpretado de forma extensiva para alcançar todo o sistema dos direitos fundamentais, inclusive os direitos sociais de prestação, que dependem de uma atuação positiva do Estado**.[24]

Conjugando-se as considerações acima, conclui-se que "a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional (como o direito à saúde), impedindo, em consequência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto na hipótese – de todo inocorrente na espécie – em que políticas compensatórias venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais".[25]

73. Quarta e finalmente, como fundamento da vedação ao retrocesso social, traz-se a sua previsão expressa no art. 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), o qual o Brasil a aderiu no ano de 1992 e aplicável ao ordenamento pátrio na forma do art. art. 5º, § 2º, da Constituição Federal:[26]

> Artigo 29 - Normas de interpretação
> Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no sentido de:
> a) permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou indivíduo, suprimir o gozo e o exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista;
> b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos Estados-partes ou em virtude de Convenções em que seja parte um dos referidos

[23] PINTO E NETTO, Luísa Cristina. **O princípio de proibição de retrocesso social.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 122.
[24] ZUBA, Thais Maria Riedel de Rezende. **O direito previdenciário e o princípio da vedação do retrocesso.** São Paulo: LTr, 2013, p. 122.
[25] RE 581352/AM, Decisão do Ministro Relator. CELSO DE MELLO. Julgado em 24/09/2013, publicado em DJe-192 DIVULG 30/09/2013 PUBLIC 01/10/201.
[26] CF/1988, art. 5º, § 2º: "Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte".

> Estados;
> **c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo;**
> **d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.**

74. No que tange ao alcance da vedação ao retrocesso social, Felipe Derbli leciona que o mesmo funciona como uma "garantia contra a ação erosiva do grau de concretização infraconstitucional de um direito social fundamental definido em uma regra ou princípio constitucional, praticada diretamente pelo legislador, ou mesmo indiretamente pelo titular do Poder Constituinte Reformador, atribuindo-se a esse direito social o *status* negativo jusfundamental e, com isso, modalidades de eficácia jurídica geralmente atribuídas aos direitos de defesa". [27]

75. Destarte, há "vedação ao legislador de suprimir, pura e simplesmente, a concretização de norma constitucional que trate do núcleo essencial de um direito fundamental social, impedindo a sua fruição, sem que sejam criados mecanismos equivalentes ou compensatórios".[28]

76. Assim, "caso se resolva alterar a lei posta pelo Estado, tal mudança não pode ser radical para fins de restringir direitos e garantias, por exemplo, mas terá de ser apresentada uma [nova] lei com caráter deveras ampliativo, para fins de manter a paz social e resguardar o direito adquirido do cidadão, as garantias e direitos fundamentais previstos na Carta Política do país.[29]

77. Nessa linha de pensamento, em relação aos objetivos do aludido princípio, torna-se possível estabelecê-los como os seguintes:[30]

(i) Proibir a supressão e/ou a redução, inclusive de forma indireta e obscura de direitos fundamentais em níveis já alcançados e garantidos aos cidadãos;
(ii) Evitar que o legislador ordinário venha a revogar integral ou parcialmente um ou mais diplomas legais (infra

[27] DERBLI, Felipe. **O Princípio da Proibição de Retrocesso Social na Constituição de 1988**. Renovar: Rio de Janeiro, 2007, p. 86.
[28] Id., *ibid*., p. 86
[29] GARCIA, Sérgio Renato Tejada. **O princípio da vedação de retrocesso na jurisprudência pátria, análise de precedentes do STF e dos TRF e da Turma Nacional de Uniformização**. Disponível em: <http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao036/sergio_tejada.html>. Acesso em: 27/07/2015..
[30] MACHADO, *ibid*., p. 152.

constitucionais) que já se concretizaram a ponto de efetivar os direitos fundamentais, limitando a reversibilidade dos direitos adquiridos;

(iii) Proteger o catálogo dos direitos fundamentais sociais, sobretudo no seu "núcleo essencial" da existência mínima inerente ao respeito pela dignidade humana; e

(iv) Invalidar qualquer norma, por inconstitucionalidade, que revoga uma norma infraconstitucional concessiva de um direito sem que seja acompanhada de uma política equivalente, deixando assim um vazio em seu lugar.

78. Voltando ao normativo ora objurgado, a permissão empreendedora pretendida pelo Estado à míngua das garantias e dos direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, sob este ponto de vista doutrinário, encontra barreira no princípio da razoabilidade, isto é, a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida.

79. Considerando que há incentivo e tentativo de fomento ao empreendedorismo de pequeno porte, que poderia contribuir para alavancar a economia nacional, deixa de criar mecanismos de incentivo e educação para que as atividades sejam desenvolvidas garantindo o mínimo existencial e capacidade de coexistir com as garantias constitucionais.

80. Ou seja, se fala em tentativa de evolução econômica sem facilitar o acesso do empreendedor ao método de realizar a atividade fim, expondo-o à possibilidade de cometer erros advindos da falta de perícia nas atividades que foram consideradas de baixo risco, mas cujas práticas de higiene foram descartadas e que podem ser o calcanhar de Aquiles do que se propõe a incorrer em tais práticas.

81. Convém destacar, sobre este propósito, as colocações deste Nobre Presidente do Supremo Tribunal, Ministro Dias Toffoli[31], com transcrição *ipsis litteris*:

> "É inegável a importância da Educação para o ser humano, para a sociedade e para o país. Entretanto, a Educação não pode ser apenas um ideal ou promessa: precisa ser um direito realizado. Há que se combater

[31] TOFFOLI, José Antônio Dias. **In Reflexões sobre Justiça e Educação**/[organização Todos pela Educação], Editora Moderna, 1ª Ed., São Paulo, prefácio, pág., 07

> as violações desse direito fundamental, que têm ocorrido em diversos níveis e têm impossibilitado que os desideratos constitucionais sejam satisfatoriamente alcançados, quais sejam, 'o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (...)'"

82. Nos termos delineados, há de se reconhecer os direitos fundamentais e os direitos humanos como valores acima de quaisquer outros deve implicar em multidisciplinariedade, isto é, equilíbrio entre todas as forças que movimentam a sociedade para que suas Constituições possam ser efetivas e não apenas um discurso literário, face as dificuldades da prática antagônica, evitando-se recair em uma constitucionalização simbólica[32] e que possibilita, por meio de legislações infraconstitucionais, que a sociedade seja imergida em verdadeiro retrocesso social gerando processo de autodestruição.

83. Inclusive, há de serem consideradas primordiais as reflexões acerca da função social do direito e seu papel como freio à banalização doutrinária e jurisprudencial ante a prática-forense e o desenvolvimento do Poder Judiciário na sociedade, sob um prisma do Direito Comparado e a morosidade do Estado esparzindo entraves burocráticos na sociedade brasileira[33] – aqui, questiona-se a gama de processos de responsabilização que poderiam advir de atividade comercial desenfreada sem atingir os critérios mínimos de higiene na condução do serviço ou preparo de alimentos.

84. Vive-se momento em que o Direito enfrenta uma "autopoiese", fechando-se para qualquer influência externa e culminando em uma multiplicação de regras jurídicas que nem sempre atendem ou efetivam o provimento jurisdicional; isto é, há uma gama de direitos internos e transnacionais que nem sempre atingem a sua finalidade, reduzindo-se a mera condição simbólica em textos normativos, como exposto anteriormente[34] – e a legislação vigente, que aqui se vergasta, apenas reforça as razões apresentadas neste instrumento.

85. Por corolário lógico, é imperioso que se priorize a aplicação do texto constitucional como norte para a legislação ordinária. As raízes da epistemologia jurídica devem ser engendradas pelo monitoramento do mundo como um todo, projetando as evoluções das sociedades dentro da realidade brasileira para, com vistas à tutela aperfeiçoada e a função social do direito, alcançar-se a Justiça em sua plenitude e um

[32] KNOERR, Viviane Coêlho de Séllos e Fernando Gustavo, p. 146.
[33] MACEDO, Daniel. **A função social do direito à luz do direito comparado e o crocodilo de Dostoievski**. **Revista Jus Navigandi**, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 19, n. 3965, 10 maio 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/28146>. Acesso em: 10 abr. 2019
[34] Idem.

sistema eficiente, livre de desembaraços burocráticos e tecnocráticos[35].

86. Com efeito, "*embora a existência de um amplo catálogo de direitos fundamentais seja importante, verifica-se que esse elemento normativo, por si só, não é suficiente para garantir a ampla eficácia dos direitos fundamentais e das decisões proferidas em ações estruturais, existindo outros elementos ou componentes do sistema legal que devem estar presentes e ser ajustados para a maior efetividade das decisões judiciais*"[36]. É necessário o reconhecimento de que a tutela dos direitos deve observar os elementos e princípios norteadores da vida coletiva, sem que haja desapreço e desconsideração do que foi conquistado às custas de anseio por punição para correção social, passível de contrariar o Estado Democrático de Direito.

87. O Estado está vinculado à concretização de regras abstratas transmutadas em direitos, sendo-lhe vedado restringir ou violá-los no plano legislativo e executivo, sendo que o principal remédio contra o arbítrio é a constituição de um poder a quem se confia o ofício de estabelecer leis certas e fixas, iguais para todos[37]; se há o conjunto normativo regido pela Lei Maior, deve ser esta última o elemento norteador da autoridade constituinte. A não observância de todo o conjunto normativo que rege a sociedade implica em início de regressão de conquistas ao argumento de que seria renovação social, o que se mostra demasiadamente temerário. Neste sentido, Ingo Wolfgan Sarlet[38] nos ensina que:

> Negar reconhecimento do princípio da proibição de retrocesso significaria, em última análise, admitir que os órgãos legislativos (assim como o poder público de modo geral), a despeito de estarem inquestionavelmente vinculados aos direitos fundamentais e às normas constitucionais em geral, dispõem do poder de tomar livremente suas decisões mesmo em flagrante desrespeito à vontade expressa do Constituinte"

88. A Medida Provisória e seu dispositivo impugnado **violam**

[35] MACEDO, Daniel. **A função social do direito à luz do direito comparado e o crocodilo de Dostoievski.** Idem.

[36] DANTAS, Eduardo Sousa. **Ações Estruturais e o estado de coisas inconstitucional – a Tutela dos direitos fundamentais em casos de graves violações pelo Poder Público**, p. 182.

[37] BOBBIO, Norberto. **Dicionário de Política** / Norberto Bobbio, Nicola Matteuci e Gianfranco Pasquino; tradução Carmen C. Varriale, 5ª ed. – Brasília. Editora Universidade de Brasília. São Paulo. Imprensa Oficial do Estado, 2000, p. 351.

[38] ARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais**. 2° ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 162.

frontalmente o Princípio da Proibição de Retrocesso Social, princípio constitucional sedimentado que possui o desiderato de preservação de direitos conquistados sem que haja quaisquer supressões de direitos fundamentais advindas de textos normativos; especialmente textos editados às pressas, sem maior observância e cautela com garantias constitucionais como o direito à saúde aqui defendido.

89. Portanto, o inciso I do artigo 3º da MP 881/2019 e o disposto na Resolução nº 51 do Ministério da Economia originam e perpetuam o espectro daquilo que pretende se combater: crise. A criação de permissivo legal para desembaraçar a atividade empresarial acaba desestabilizando as instituições ao criar facilidade de um lado, enquanto onera outro lado com as consequências da mencionada facilidade. Todo o sistema se funda num conjunto de relações mais ou menos estreitamente coligadas entre os vários componentes, de tal forma que a mudança num dos componentes do sistema gera mudanças em todos os outros componentes.

90. Todavia, enquanto nos sistemas mecânicos é possível avaliar cuidadosamente o efeito e a amplitude de semelhantes variações e até medi-las, no âmbito dos sistemas sociais se está ainda longe disso. Para avaliar, em sentido lato, a incidência de uma crise sobre um sistema social – *in casu*, a lentidão econômica que surge como elemento justificador da dispensa de fiscalização de condições sanitárias –, entretanto, é preciso, antes de mais nada, definir o estado de equilíbrio deste sistema. O sistema pode encontrar-se em equilíbrio estável, de tal maneira que tende a voltar à mesma posição, logo que passar a perturbação ou pode estar em equilíbrio instável, de tal maneira que tende a alcançar um novo tipo de equilíbrio após as perturbações e as crises por que passou[39].

91. A justificativa de sobrecarga na economia nacional e lentidão no processo de sua recuperação não deve ser motivação para atropelamento legitimado de outros pontos de equilíbrio normativo protegidos pela constituição. Ignorar tais preceitos e extirpar o direito à saúde com políticas públicas sem controle seria ferir, gravemente, a preservação do progresso social e condená-lo ao retrocesso com permissivos que podem se espalhar por toda a sociedade brasileira.

V. DA MEDIDA CAUTELAR.

92. Os artigos 10 e 11 da Lei nº 9.868/1999 admitem a possibilidade de deferimento de medida cautelar no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade por decisão da maioria absoluta deste E. Supremo Tribunal Federal.

[39] Cf. BOBBIO, Norberto. **Dicionário de Política,** p. 301.

93. A concessão de cautelar está condicionada à satisfação de certos requisitos relativamente à existência (a) do *fumus boni iuris*, ou seja, a plausibilidade jurídica dos fundamentos invocados e (b) do *periculum in mora*, isto é, da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora da decisão final.[40]

94. Conforme demonstrado nas razões desta ação e pelos motivos esposados, **estão presentes os dois requisitos**.

95. A fumaça do bom direito restou devidamente comprovada diante dos argumentos trazidos. O partido **SOLIDARIEDADE** demonstrou cabalmente o seguinte:

- O teor do dispositivo impugnado viola frontalmente o direito à saúde, previsto no **artigo 6º, inciso II do artigo 23, artigo 196 e artigo 197 da Constituição Federal**;
- Igualmente, o teor do dispositivo da norma objurgada desrespeita o princípio de vedação do retrocesso social;
- A manutenção do dispositivo poder refletir em constantes e reiteradas violações ao direito constitucionalmente garantido, além de gerar possíveis desdobramentos acerca de eventual responsabilização dos que incorrerem em práticas danosas à sociedade advindas da ausência de necessidade de fiscalização prévia das boas práticas de higiene na produção, fabricação e venda de produtos alimentícios e de serviços de estética/embelezamento e seus equipamentos, jamais se falando sobre providências que seriam tomadas para reparar os danos à saúde que poderiam ser causados.

96. Do mesmo modo, está presente o perigo da demora, em várias frentes, mormente se considerar a inadequação do dispositivo ao ordenamento jurídico pátrio vigente e como sua aplicação também destoa de todo o acervo normativo constituído.

97. Caso mantidos os efeitos do dispositivo ora impugnado, as constantes violações aos direitos e garantias constitucionais continuarão sendo maculadas ao argumento de "facilitar o início da atividade empresarial de baixo risco"; **tal hipótese, obviamente, resultaria em flagrante afronta às condições sanitárias mínimas já que**

[40] CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. In DIDIER FR, Fredie (org.). **Ações constitucionais**. 3ª Ed. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 491-554.

não há a necessidade de adequação à norma, inicialmente.

98. **O perigo da demora está calcado justamente na legitimação da violação destes direitos, que ocasionará verdadeiro retrocesso social ao permitir e facilitar que a saúde coletiva seja comprometida**.

99. Necessário enfatizar que o autor, **SOLIDARIEDADE**, **em nenhuma hipótese milita contra o progresso social e medidas que possam reaquecer a economia do país, tampouco o acesso do brasileiro ao empreendimento próprio**. Há, tão somente, necessidade de demonstrar que a estrutura normativa contida no dispositivo afronta, e muito, as disposições constitucionais, que carece de imediato provimento deste Excelso Pretório; "*trata-se, pois, de um sopesamento (balanceamento) dos valores do ordenamento jurídico, em que se procura atingir a mais oportuna relação entre meios e fins para melhor garantir os direitos do cidadão em situações concretamente relacionadas*"[41]

100. **Por derradeiro, mostra-se completamente plausível e razoável salientar que, conforme escólio de Gustavo Binenbojm[42] "*a atuação administrativa só será válida, legítima e justificável quando condizente, muito além da simples legalidade, com o sistema de princípios e regras delineado na Constituição, de maneira geral, e com os direitos fundamentais em particular*", corroborando o caráter irrefragável do princípio da legalidade e da proporcionalidade aos quais está submetida a Administração Pública.**

VI. DOS PEDIDOS E DOS REQUERIMENTOS.

101. Ante o exposto, E. Supremo Tribunal Federal, o partido **SOLIDARIEDADE** requer e pede:

I. O conhecimento e processamento desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, porquanto preenchidos seus pressupostos de admissibilidade;

II. Na forma dos artigos 10 e 11 da Lei nº 9.868/1999, o deferimento de medida cautelar, para suspender imediatamente a eficácia das disposições aqui impugnadas

[41] TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo : Saraiva, 2012, p. 783.
[42] BINENBOJM, Gustavo. **Uma teoria do Direito Administrativo. Direitos Fundamentais, Democracia e Constitucionalização**. 2ª ed. São Paulo: Renovar, 2008, p.132.

com efeitos *erga omnes*, efeitos *ex nunca e ex tunc*;

III. Caso não deferido o pedido (II), que a Nobre Relatoria imprima à presente ADI o rito sumário do artigo 12 da Lei nº 9.868/1999 em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social, constitucional e até mesmo econômica, pois, conforme demonstrado passou a ser permitido o início das atividades que envolvem alimentos e tratamentos cosméticos descritas como de baixo risco sem a necessidade de atos públicos, dentre eles alvará da vigilância sanitária por meio da norma ora impugnada, ferindo gravemente direitos constitucionais e os dispositivos do Texto Maior aqui evidenciados;

IV. Qual seja o rito a ser adotado – o sumário do artigo 12 da Lei nº 9.868/1999 ou o ordinário do referido diploma –, sejam solicitadas informações às autoridades das quais emanou a lei impugnada (cf. artigo 6º da Lei nº 9.868/1999);

V. Decorrido o prazo das informações, seja determinada a oitiva sucessiva do Exmo. Advogado-Geral da União e do Exmo. Procurador-Geral da República (cf. artigo 8º da Lei nº 9.868/1999); e

VI. Após o devido processo legal, no mérito, a procedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para que seja declarado **INCONSTITUCIONAL**, por violação direta ao **artigo 6º, ao inciso II do artigo 23, ao artigo 196 e ao artigo 197 da Constituição Federal de 1988** – declaração esta com caráter vinculante, *erga omnes*, efeitos *ex tunc e ex nunc* –, atual inciso I do artigo 3º da Medida Provisória nº 881, editada em 30 de abril de 2019 em conjunto com o inciso I do artigo 2º e §1º do artigo 2º da Resolução nº 51 do Ministério da Economia, editada em 11 de junho de 2019.

102. Requer-se que as publicações sejam feitas, **exclusivamente**, em nome de DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.0402, sob pena de nulidade.

103. Dá-se a causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), para fins fiscais.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Brasília/DF, 26 de junho de 2019.

Assinado eletronicamente
Daniel Soares Alvarenga de Macedo
OAB/DF nº 36.042

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS.

Doc. 01. Procuração com poderes específicos.

Doc. 02. CNPJ do SOLIDARIEDADE.

Doc. 03. Estatuto social do SOLIDARIEDADE.

Doc. 04. Comprovação de que o autor tem representantes no Congresso Nacional.

Doc. 05. Cópia do atual inciso I do artigo 3º da Medida Provisória nº 881, editada em 30 de abril de 2019, e do inciso I do artigo 2º e §1º do artigo 2º da Resolução nº 51 do Ministério da Economia, editada em 11 de junho de 2019.

Doc. 06. Guia de custas.

Doc. 07. Comprovante de pagamento.

SRTVS QD 701, Bloco O, Sala 278, Ed. Multiempresarial-DF - Asa Sul - Brasilia - DF